

1505997-47.2021.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... em crimes de elevada gravidade como o de tráfico de drogas, cujas testemunhas se abstêm de prestar declarações às autoridades policial ou judicial por respeito à "lei do silêncio" e por temor a represálias. Nesse sentido, a propósito, é a pacífica posição da jurisprudência do E. TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Preliminar de cerceamento de defesa, no caso, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1505997-47.2021.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505997-47.2021.8.26.0132

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2302784/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 21248450 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

5397/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2302784 - DEL.INV.GER. CATANDUVA,

5397/21/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONALDO DIEGO DE OLIVEIRA CINCO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Ronaldo Diego de Oliveira Cinco dando-o como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06, pois, em horário incerto, na Rua Campos do Jordão, n. 520, Jardim Alpino, nesta cidade e Comarca, ele trazia consigo sessenta e seis pinos de crack, para fins de mercancia, quando foi flagrado pela Polícia Militar (fls. 73/74).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia seguinte (fls. 36/38).

Em sede de defesa preliminar foi alegada a inexistência da infração penal (fls. 94/103).

A denúncia foi recebida em 17 de janeiro de 2022, oportunidade em que mantida a

prisão preventiva (fls. 112/113).

O acusado foi citado (fl. 150).

No curso da instrução foram ouvidas cinco testemunhas e interrogado o acusado, que negou a prática delitiva.

Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram e, em alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da pretensão punitiva estatal ao passo que a Defesa suscita a nulidade atinente à cadeia de custódia, a imprestabilidade do "interrogatório informal" realizado pelos policiais militares e das provas que são dele decorrentes, e, no mérito, pugna pela absolvição pela insuficiência de provas e pela desclassificação da imputação (fls. 170/184).

É o relatório.

Fundamento e decido.

De plano, rechaço a preliminar de nulidade atinente à inobservância da cadeia de custódia, ausência de fotografias dos objetos apreendidos e de realização de exame datiloscópico.

À toda evidência, com o escopo de garantir a autenticidade, a idoneidade, a confiabilidade e a transparência da coleta dos vestígios em geral e da produção das provas no âmbito do processo penal, a Lei 13.964/19 inseriu no CPP disposições regulamentadoras da sistemática denominada de cadeia de custódia. Em última análise, as noveis previsões têm "como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita".

Nos termos do art. 158-A do CPP, "Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.". Noutras palavras, cuida-se de "um procedimento de documentação ininterrupta, desde o encontro da fonte de prova, até a sua juntada no processo, certificando onde, como e sob a custódia de pessoas e órgãos foram mantidos tais traços, vestígios ou coisas, que interessam à reconstrução histórica dos fatos no processo, com a finalidade de garantir sua identidade, integridade e autenticidade.".

Ocorre que não obstante o legislador tenha sido extremamente detalhista em boa parte da abordagem à matéria, inclusive se imiscuindo em temas que melhor poderiam ser tratados em atos regulamentares, olvidou-se de fixar as consequências decorrentes da "quebra" da cadeia de custódia, o que inequivocamente ocasionou divergência no âmbito doutrinário.

De um lado, há firme posição no sentido de que a violação à cadeia de custódia só pode ensejar a inadmissibilidade da prova, nos exatos termos do art. 157 do CPP. Por outro vértice, há corrente a sustentar que a quebra da cadeia de custódia é questão a ser objeto de valoração, de modo que a prova permaneceria lícita e legítima, porém a qualidade e, por corolário, o seu valor deveria ser sopesado.

Esse é o posicionamento do Des. Guilherme de Souza Nucci:

É preciso frisar que o Brasil é um País continental, de modo que a cadeia de custódia pode ser bem executada no estado mais rico, como o Paraná, mas pode enfrentar muitas dificuldades, até pelas imensas distâncias, em estados como o Amazonas. Portanto, o simples descumprimento da cadeia de custódia não deve gerar nulidade absoluta.

Comungo desse entendimento. Sem embargo da corrente que sustenta a imediata e absoluta inadmissibilidade da prova, parece-me mais apropriada a tese que assenta que as irregularidades constantes da sistemática de custódia devem ser sopesadas pelo julgador, juntamente com todos os demais elementos de convencimento produzidos, a fim de se aferir a sua confiabilidade.

Nessa esteira, vale registrar, leciona Leonardo Barreto Monteiro Alves:

É dizer, a quebra da cadeia de custódia não resulta, necessariamente, em prova ilícita ou ilegítima, interferindo apenas na valoração dessa prova pelo julgador. A irregularidade na cadeia de custódia reduzirá a credibilidade da prova, diminuirá o seu valor, passando-se a ser exigido do juiz um reforço justificativo caso entenda ser possível confiar na integridade e na autenticidade da prova e resolva utilizá-

la na formação do seu convencimento. Enfim, “a quebra da cadeia de custódia não significa de forma absoluta, a inutilidade da prova colhida. É preciso não se esquecer que a cadeia de custódia existe não para provar algo, mas para garantir uma maior segurança – dentro do possível – à colheita, ao armazenamento e à análise pericial da prova [...]. Desta forma, a análise do elemento coletado e periciado, se houver quebra dos procedimentos de cadeia de custódia, interferirá apenas e tão somente na valoração dessa prova pelo julgador.

E esse também é o atual posicionamento do C. STJ:

As irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. (STJ. 6ª Turma. HC 653515-RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. Acđ. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 23/11/2021) (Info 720).

Além do mais, por força do princípio do prejuízo, insculpido no art. 563 do CPP, é lição há muito consolidada nas esferas doutrinária e jurisprudencial que a demonstração do prejuízo é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta.

No caso, não há se falar em nulidade decorrente da inobservância da cadeia de custódia, nem mesmo pela ausência de fotografias das drogas encontradas e apreendidas.

Nesse ponto, deve se observar que parte dos materiais ilícitos foram recolhidos pelos policiais em posse do acusado, ao passo que outra parcela das drogas estava em uma praça pública. É incabível, nessas situações, o acionamento de órgão técnico para realização de exame em local e fotografias, sob pena de inviabilizar a persecução penal nos mais diversos crimes, motivo pelo qual as novéis disposições acerca da cadeia de custódia devem ser vistas à luz do caso concreto.

Na mesma linha, não melhor sorte assiste à Defesa quanto ao pedido de exame pericial datiloscópico no material apreendido, porquanto absolutamente impossível de ser realizado.

Ora, é consabido que o exame datiloscópico é deveras complexo e sua efetividade depende de uma série de fatores que muito dificilmente se verificam na prática, sobretudo àqueles atinentes ao pleno isolamento do local do crime e do material a ser examinado.

Em se tratando de apreensão de entorpecentes, é inequívoco que os agentes públicos que os localizaram mantiveram contatos, deixando neles os fragmentos de digitais. Logo depois, em vista da rotina policial e dos procedimentos inerentes à cadeia de custódia, certo é que o material apreendido foi repassado a policiais civis e, por fim, a peritos, para fins da realização de exame de constatação de substância entorpecente. E mesmo antes da apreensão das drogas é certo que um sem-número de pessoas manuseou a embalagem.

Quer dizer, se houver fragmentos de digitais, certamente haverá de inúmeras pessoas, inclusive com sobreposições de fragmentos a impedir a identificação. Logo, afasto as preliminares de nulidade relativa à cadeia de custódia.

Por sua vez, no tocante ao “interrogatório informal”, realizado pelos policiais militares, em via pública, sem documentação e preservação mínima dos direitos e garantias fundamentais, tenho que são totalmente desprovidos de valor probantes, razão pela qual não são, a rigor, utilizados como fator de convencimento por este Juízo – inclusive à luz do que foi recentemente decidido pelo STF:

A CF/88 determina que as autoridades estatais informem os presos que eles possuem o direito de permanecer em silêncio (art. 5º, LXIII). Esse alerta sobre o direito ao silêncio deve ser feito não apenas pelo Delegado, durante o interrogatório formal, mas também pelos policiais responsáveis pela voz de prisão em flagrante. Isso porque a todos os órgãos estatais impõe-se o dever de zelar pelos direitos fundamentais. A falta da advertência quanto ao direito ao silêncio torna ilícita a prova obtida a partir dessa confissão. STF. 2ª Turma. RHC 170843 Agr/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4/5/2021 (Info 1016).

Importa ainda ressaltar que, sem embargo de posicionamentos distintos do próprio E. TJSP, para além da observância do direito ao silêncio no âmbito dos interrogatórios formais, ou seja, aqueles prestados perante as autoridades policial e judiciária, a advertência do direito ao silêncio deve ser realizada também pelos policiais

responsáveis pela “voz de prisão” – conforme decidido pelo STF no bojo do RHC 192798 AGR/SP.

Não se valora, portanto, suposta confissão informal. Entretanto, como no caso nenhuma prova decorreu dessa suposta admissão de culpa, a qual sequer foi confirmada pelos policiais militares em Juízo, não há se falar em declaração de nulidade probatória. Quer dizer, as provas constantes dos autos foram produzidas de maneira independente da alegada confissão informal, sem qualquer nexo de causalidade, de modo que não se aplica o disposto no art. 157, §1º, do CPP.

Assim sendo, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito.

Diante do arcabouço probatório produzido, a pretensão punitiva deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 26/27), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 21), pelos laudos de constatação preliminar e definitivas de substância entorpecente (fls. 23/25, 54/56 e 60/62) e por todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos.

Por seu turno, a autoria também é certa e repousa sobre o ora réu.

Com efeito, o policial militar Dirceu Marques Fernandes Júnior, em Juízo, declarou que na data dos fatos realizava patrulhamento em localidade conhecida pela intensa traficância de drogas quando avistou, em uma praça, o réu agachado, mexendo em algo no chão. Disse que o réu empreendeu fuga assim que viu a viatura, mas foi perseguido e abordado, sendo que em seu poder havia três pinos de crack. Contou que no local em que o réu estava agachado foram encontrados sessenta e três pinos da mesma droga. Asseverou que o réu ficou nervoso quando questionado sobre as drogas e foi preciso o uso da força para contê-lo. Respondeu que não havia outras pessoas perto do local em que foram encontradas as drogas e que não foi vista negociação com terceiros ou atividade similar.

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Maxwell Roberto Almeida Domingos, o qual confirmou que o acusado estava agachado, mexendo em algo, exatamente no local em que foram recolhidos sessenta e três pinos de crack de características idênticas às dos três pinos apreendidos em poder do agente.

As testemunhas Diva Aparecida Bessa, Elaine Cristina Ribeiro e Sidney de Jesus Macedo não ingressaram no âmago da demanda, pois ativeram-se a declarar que o acusado é trabalhador, que presta diversos tipos de serviços relacionados a pinturas e consertos, e que é usuário de drogas, sem qualquer tem relação com o tráfico. Disseram, também, que não costumam ver o acusado na praça onde as drogas foram encontradas.

Por ocasião de seu interrogatório, o acusado negou a traficância de drogas e afirmou que o flagrante foi forjado pelos policiais militares, os quais o abordaram enquanto ele conversava com conhecidos e lhe exigiram que prestasse informações acerca de algum ponto de venda de drogas. Disse que se negou a colaborar com os policiais, e então, assim como a sua esposa, foi agredido por eles. Respondeu desconhecer a origem das drogas apreendidas pelos policiais.

Ocorre que a partir da detida análise dos elementos informativos e probatórios carreados nos autos, conclui-se que a negativa de autoria trazida pelo réu está absolutamente insulada, pois não é corroborada por documentos, testemunhas ou qualquer outra notícia formalmente inserida no caderno processual – além do que exige pressupor que as drogas apreendidas foram criminosamente plantadas pelos agentes públicos em seu desfavor, tudo, frise-se, sem base probatória.

Lado outro, os testemunhos dos policiais militares são firmes, uníssonos, detalhados e coesos.

No ponto, conquanto não sejam dotados de presunção processual de veracidade nem possuam valor probatório superior às demais provas admitidas no campo do processo penal, os testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão não podem ser indistintamente desconsiderados tão somente pela natureza da função que exercem, sobretudo quando coesos e uniformes, como no caso. Ademais, não se pode olvidar que nas ações penais lastreadas em autos de prisão em flagrante corriqueiramente as únicas testemunhas são exatamente os policiais responsáveis pela prisão,

especialmente em crimes de elevada gravidade como o de tráfico de drogas, cujas testemunhas se absterem de prestar declarações às autoridades policial ou judicial por respeito à “lei do silêncio” e por temor a represálias. Nesse sentido, a propósito, é a pacífica posição da jurisprudência do E. TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Preliminar de cerceamento de defesa, no caso, confunde-se com o mérito. Ausência de prova do prejuízo. Absolvição. Materialidade e autoria comprovadas. Conjunto probatório firme e seguro a demonstrar a destinação mercantil da droga. Valorização das palavras dos policiais responsáveis pela prisão dos réus. Impossibilidade de desclassificação do crime para o de porte para uso próprio. Penas inalteradas. Artigo 41 da Lei de Drogas. Afastamento. Réu não colaborou com as investigações. Regime prisional mantido no fechado. APELO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500606-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cajuru - Vara Única; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020) Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição. Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Razoável quantidade de drogas e circunstâncias da prisão – Reprimenda. Redução. Afastamento da circunstância judicial desfavorável. Quantidade de droga que não pode ser considerada expressiva – Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500097-75.2019.8.26.0610; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Morro Agudo - Vara Única; Data do Julgamento: 13/11/2020; Data de Registro: 13/11/2020)

No caso, a Defesa não apresenta elementos objetivos que possam colocar em dúvida a imparcialidade dos agentes públicos e a veracidade dos seus depoimentos, que, frise-se, são firmes, coesos e uníssonos, além de corroborados e confirmados pelos demais elementos informativos e probatórios disponibilizados nos autos, dentre os quais vale destacar, uma vez mais, a apreensão das substâncias entorpecentes. A bem da verdade, como ocorre na maioria dos casos similares, chocam-se as versões dos responsáveis pela prisão com a do acusado, e, de acordo com o entendimento pacífico do E. TJSP e também dos Tribunais Superiores, deve prevalecer aquela, desde que ausentes vícios comprovados e apesar do ônus da prova e do poder estatal de investigação.

Veja-se, ademais, que no presente caso aparentemente a Defesa poderia ter produzido provas para amparar a versão do réu, já que ele citou pessoas que, em tese, teriam presenciado a abordagem. Todavia, as pessoas ouvidas em Juízo nada viram ou sabiam a respeito dos fatos.

De mais a mais, a natureza e a quantidade de droga apreendida, a forma de armazenamento e acondicionamento das substâncias, a localidade em que ocorreram os fatos, a qual é amplamente conhecida pelo intenso comércio de drogas, e os antecedentes do acusado, que cumpre pena por tráfico de drogas, permitem concluir que o material tóxico não era destinado ao consumo pessoal, e sim à comercialização. Incabível, destarte, a desclassificação da imputação penal. Destarte, tanto a existência quanto a autoria do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 estão cabalmente comprovadas nos autos, não havendo se falar em insuficiência probatória ao decreto condenatório, aplicação do princípio do in dubio pro reo ou mesmo desclassificação. A prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe. Passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP.

Na primeira fase, em análise ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 e no art. 59 do CP, conclui-se que a natureza e a quantidade de substância apreendida não revelam gravidade anormal a justificar o incremento da pena-base. A culpabilidade, tida como o grau de reprovabilidade do comportamento, é insita ao tipo penal. O réu ostenta mais de uma condenação transitada em julgado, de modo que, nesta fase, utilizo uma delas (autos n. 0006905-04.2009.8.26.0132), evitando-se, assim, o bis in idem (Súmula 241 do STJ). Ausentes provas acerca da conduta social do agente. A personalidade é circunstância neutra ante a falta de amparo probatório. O motivo do crime é próprio à espécie, assim como as suas circunstâncias e consequências. Não

há comportamento de vítima a ser valorado. Logo, considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável, e tendo em vista o entendimento do STJ no AgRg-HC 547.176, de que cada circunstância deve ser valorada, a rigor, no patamar de um sexto, fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Na segunda fase, ausentes atenuantes de pena. Lado outro, presente a agravante da reincidência específica (art. 61, I, c.c 63 do CP), diante da condenação definitiva imposta nos autos n. 1500921-13.2019.8.26.0132. Assim, agravo a pena intermediária em um sexto, fixando-a em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. Na terceira e derradeira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento. Registre-se que não cabe, no caso, a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é reincidente, o que, por si só, obsta a aplicação da benesse. A pena definitiva, então, é de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 43 da Lei 11.343/06 c.c art. 49, §1º, e 60 do CP), ante a ausência de informações sobre a capacidade econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, diante do teor do art. 33, §§2º, 'b', e 3º, do CP, da reincidência e da circunstância judicial desfavorável. Tal cenário não resta alterado, por ora, pela aplicação do disposto no art. 387, §2º, do CPP.

Diante da natureza da infração, da reincidência e da quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, inviável a sua substituição por restritiva de direitos ou sua suspensão condicional (art. 44 da Lei 11.343/06 e arts. 44, I e II, e 77, I, do CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado Ronaldo Diego de Oliveira Cinco como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06, à reprimenda de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente à época do fato.

Por se tratar de crime vago, não há se falar em fixação de valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Porquanto permanecem hígidos os cenários fático e jurídico que outrora ensejaram a decretação da prisão preventiva, mantenho-a. Com efeito, enquanto o fumus comissi delicti resta verificado em sede de cognição exauriente, o periculum in libertatis é extraído da gravidade em concreto das condutas do acusado, cujos antecedentes indicam a habitualidade delituesa e a periculosidade social, o que inequivocamente ocasiona severo e concreto risco à ordem pública e aponta que a libertação lhe permitirá retornar ao seio propício à atividade de traficância. Logo, a segregação cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, motivo pelo qual, com fulcro no art. 387, §1º c.c 311, 312 e 313, I e II, do CPP, mantenho-a. Recomende-se o réu à prisão.

Condene o acusado, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, sem embargo da suspensão da exigibilidade do encargo em razão da aplicação analógica do art. 98, §3º, do CPC c.c art. 3º do CPP.

Em observância ao art. 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das amostras de substância entorpecente guardadas para contraprova, com certificação nos autos, e, com base no art. 63, I, da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do numerário apreendido nos autos.

Proceda-se às comunicações de praxe, e com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF), intime-se o réu para pagamento da multa no prazo de dez dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP) e expeça-se a guia de execução, assim como o que mais for cabível.

P. I. C., com observância do art. 392 do CPP.

Catanduva, 11 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA